

1501002-91.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/05/2022

... como incurso nas penas do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Narra a denúncia que, no dia 1º de maio de 2021, por volta das 17h10, Rua Rubens Pimentel de Medeiros, 1871, bairro Miguel Badra Alto, nesta cidade e comarca de Suzano/SP, o Réu trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 11 (onze) invólucros plásticos com cocaína, com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501002-91.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501002-91.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2118626/2021 - DEL.POL.SUZANO, 17663632 - DEL.POL.SUZANO, 1700/21/309 - DEL.POL.SUZANO, 2118626 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Danilo Fidelis Nunes

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Vistos.

Danilo Fidelis Nunes, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Narra a denúncia que, no dia 1º de maio de 2021, por volta das 17h10, Rua Rubens Pimentel de Medeiros, 1871, bairro Miguel Badra Alto, nesta cidade e comarca de Suzano/SP, o Réu trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 11 (onze) invólucros plásticos com cocaína, com peso líquido de 4,46g; 09 (nove) invólucros plásticos com Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, com peso líquido de 17,51g; e 18 (dezoito) frascos de lança perfume, com 719,4 mililitros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Laudo prévio de constatação da droga às fls. 20/25.

Certidão de antecedentes criminais do Réu às fls. 50/52.

Laudo de exame pericial químico-toxicológico definitivo às fls. 105/107.

Laudo de exame pericial de local às fls. 112/115.

Regularmente citado e notificado (fl. 126), o Réu apresentou defesa prévia às fls. 132/133.

A denúncia foi recebida às fls. 142/143, em 10 de fevereiro de 2022.

Laudo de exame pericial químico-toxicológico do “lança-perfume” às fls. 181/183.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas Igor Buccini Leite e Welder Marques da Silva, bem como interrogado o Réu. Encerrada a instrução, foram apresentadas alegações finais escritas pelo Ministério Público e pela Defesa, às fls. 188/191 e 194/206, respectivamente.

É o relatório. Fundamento e decido.

1. Das Questões Preliminares

Inicialmente, rejeito a alegação da Defesa quanto à suposta ausência de justa causa para o recebimento do aditamento da denúncia realizado pelo Ministério Público à fl. 188, posto que a modificação realizada pelo Parquet se baseou na superveniência do laudo de exame pericial de fls. 112/115, não havendo que se falar em ausência de suporte probatório.

No que se refere aos parâmetros de aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 – objeto do referido aditamento da exordial –, esses se confundem com o mérito, sendo, portanto, com este analisados.

Assim, tendo em vista o princípio *pas de nullité sans grief*, segundo o qual não se deve reconhecer nulidade quando inexiste prejuízo ao trâmite processual e, por consequência, violação aos princípios basilares que norteiam o devido processo legal, recebo o aditamento à denúncia de fls. 188/191.

2. Do Mérito

No mérito, a presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 05/09, pelo auto de exibição/apreensão de fls. 17/18, e pelos laudos prévios e definitivos da droga de fls. 20/25 e fls. 105/107 e 181/183, respectivamente.

A autoria do delito foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 04) e demais provas produzidas em juízo.

Em audiência de instrução, a testemunha Welder Marques da Silva, guarda municipal, relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento de rotina pelo bairro do Miguel Badra com seu companheiro de equipe, quando suspeitaram que o Réu estava vendendo entorpecentes. Verificaram que o acusado passou algo para um indivíduo e, em revista pessoal, encontraram dinheiro e drogas em sua posse. Em varredura próxima ao local, encontraram mais entorpecentes, os quais possuíam as mesmas características dos que foram localizados com o acusado. Essas drogas estavam a cerca de dois ou três metros de distância do Réu, próximo a uma árvore. Não conhece o acusado de outras abordagens.

No mesmo sentido, a testemunha Igor Buccini Leite, guarda municipal, narrou que estava em patrulhamento com seu companheiro de equipe em local conhecido pelo tráfico de entorpecentes, quando avistaram o Réu em atitude suspeita, consistente em nervosismo. Resolveram abordá-lo e encontraram drogas e dinheiro em sua posse. Em varredura no local, encontraram mais drogas que tinham as mesmas características daquelas que o acusado trazia consigo.

As provas colhidas sob a égide do princípio constitucional do contraditório fundamentam o decreto condenatório, não havendo de se falar em dúvida ou insuficiência aptas a beneficiar o acusado.

Com efeito, os depoimentos dos guardas municipais que participaram das diligências, na qualidade de agentes públicos, fornecem embasamento suficiente para respaldar o pedido de condenação, tendo em vista a segurança e a coerência com que foram prestados, sendo certo que não se deve desconsiderar o teor de seus relatos apenas em razão de sua condição funcional.

Nesse sentido, é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, *in verbis*:

“Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo” STJ - HC 177980/BA rel. Min. Jorge Mussi J. 28/06/2011, e “Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o

que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório" (STJ - HC 30776 / RJ rel. Min. Laurita Vaz DJ 08.03.2004 p. 304).

No mesmo teor, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIAS DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações" STF HC 87662/PE rel. Min. Carlos Britto - J. 05/09/2006.

Em outras palavras, o depoimento dos agentes públicos só deve ser visto com reservas quando verificar-se a existência de interesse, como, por exemplo, para justificar eventual abuso de sua parte. No caso dos autos, não se vislumbra tal hipótese, tanto que as testemunhas sequer foram contraditadas, prestando depoimentos harmônicos e coesos.

Ademais, os guardas municipais abordaram o Réu em razão de fundada suspeita - haja vista que o acusado se encontrava em local conhecido por ser ponto de venda de entorpecentes, demonstrando nervosismo, logo após repassar algo a terceiro -, estando a sua atuação dentro dos estritos limites legais e constitucionais de suas funções, inexistindo nos autos provas que permitam inferir motivos para falsa incriminação, ou, ainda, quaisquer outros elementos que mitiguem os seus relatos em juízo.

Destaca-se, ainda, que as testemunhas e o Réu não se conheciam previamente, antes dos fatos narrados, não havendo razão para que fosse realizada criminalização infundada.

Ademais, os guardas municipais, na qualidade de agentes públicos, possuem atuação dotada de presunção de legitimidade e veracidade, o que não foi infirmado nos presentes autos.

No que tange à licitude da prova, em que pese guardas municipais não possuírem atribuições constitucionais para realizar investigação criminal, qualquer pessoa do povo pode realizar prisão em flagrante delito, consoante art. 301, CPP. No caso, os agentes públicos atuaram em local público (via pública), em situação que não exigia a expedição de mandado ou aprofundamento das investigações por parte dos órgãos competentes.

Neste sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pleito de trancamento da ação. Impossibilidade. Paciente e corréus que estavam em atitude suspeita, transportando entorpecentes. Situação de flagrância. Legalidade da prisão efetuada por guardas municipais (art. 301 do CPP) Precedentes Ordem denegada". (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2065756-68.2013.8.26.0000; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cotia - Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/08/2014; Data de Registro: 11/08/2014).

"Apelação. Tráfico de entorpecentes. Preliminar. Alegada nulidade da prova colhida pela guarda municipal. Inexistência de ilicitude da prova. Guarda municipal prevista no art. 144, § 8º, da CF, e regulamentada pela Lei 13.022/14. Expressa previsão de prisão em flagrante e encaminhamento ao delegado de polícia. Outrossim, por expressa previsão do art. 301 do CPP, cabe a qualquer do povo prender quem se encontre em flagrante delito. Seria um contrassenso autorizar qualquer cidadão a

realizar a prisão em flagrante e impedir que a guarda municipal o fizesse. Prova lícita. Preliminar rejeitada. Ausência de impugnação quanto à dinâmica dos fatos. Réu confesso. Penas. Redução. Necessidade. (...)" (TJSP; Apelação Criminal 1501482-56.2020.8.26.0567; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/05/2021; Data de Registro: 30/05/2021).

Logo, não há que se falar em prova ilícita, uma vez que a atuação dos agentes públicos ocorreu em conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro, não extrapolando os limites constitucionais de sua atuação.

Por outro lado, em interrogatório, o Réu aduziu que a presente acusação não é verdadeira. Narrou que, no dia dos fatos, estava subindo a rua para comprar sorvete para o filho, quando foi abordado pelos guardas municipais. Não havia drogas e dinheiro em sua posse. Os entorpecentes estavam a cerca de cinquenta metros de distância do local em que estava passando. Contou aos guardas municipais que tinha passagem e foi levado para averiguação na Delegacia de Polícia. Informaram que iam levá-lo para assinar papéis se tivesse algo pendente. Não confessou o crime em sede policial. Não conhecia os guardas municipais de outra ocasião, nem ninguém da delegacia.

Em que pesem as alegações do acusado, não é crível que os agentes públicos o teriam imputado crime à revelia da lei e sem justificativa concreta, tão somente em razão de o Réu possuir antecedentes criminais.

No mais, não faz sentido que guardas municipais estivessem com drogas em sua posse e se dirigissem até local conhecido por ser ponto de tráfico para imputar crime a qualquer outra pessoa que encontrassem, circulando com os entorpecentes, ao invés de levá-los à delegacia.

Registre-se que os depoimentos dos agentes públicos em juízo e em sede policial não apresentam nenhuma contradição que permita inferir a ocorrência de flagrante forjado e/ou atuação fora dos ditames legais, ao passo que o acusado, em delegacia, admitiu formalmente a prática delitiva, asseverando que estava no local da ocorrência para vender entorpecentes e que, inclusive, a sacola encontrada estava em sua posse indireta (fl. 12).

Assim, a versão do Réu, em juízo, restou isolada das demais provas produzidas no curso da instrução – destacando-se a sua própria versão em sede policial –, não havendo que se falar em fragilidade probatória.

No que tange à caracterização do tráfico, as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas confirmam sua destinação, porquanto pulverizadas em pequenas porções (consoante auto de exibição de fls. 17/18, em mais de trinta e cinco unidades individualizadas), em invólucros voltados à venda ou ao fornecimento a terceiros. Além disso, a dinâmica dos fatos – consubstanciada na observação, pelos guardas municipais, de que o Réu efetivamente acabara de vender entorpecentes a terceiro, em local conhecido por ser ponto de venda de entorpecentes – não permite a desclassificação para o delito de porte para consumo próprio (art. 28, Lei nº 11.343/06), uma vez que restou comprovada que a quantidade de drogas encontrada próximo ao acusado também estava em sua posse, ainda que indireta.

Logo, inviável a desclassificação para porte para consumo próprio, ante as circunstâncias de tempo, modo e espaço, bem como pela ausência de alegação do acusado neste sentido.

Sendo assim, diante do acervo probatório produzido nos autos e inexistindo causas de exclusão da tipicidade, licitude e culpabilidade, a procedência da ação penal é medida que se impõe.

3. Da Dosimetria da Pena

Passo, então, à dosimetria da pena, atendendo às diretrizes do art. 59, do Código Penal e art. 42, Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase, estabeleço a pena-base no mínimo legal, ante a ausência de provas que permitam inferir circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou seja, em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa. Destaco que a quantidade da droga (21,97g líquidos – fl. 20) e a sua natureza não representam periculosidade à saúde pública

para além da já considerada na tipicidade comum do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Na segunda fase, incide à espécie a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), tendo em vista que o Réu possui condenação anterior (fls. 50/52 – processo nº 0000251-91.2015.8.26.0616), cujo trânsito em julgado ocorreu previamente à prática do presente delito, não tendo transcorrido ainda o período depurador. Por outro lado, presente a atenuante da confissão (art. 65, III, d, CP), uma vez que, em delegacia, o Réu assumiu integralmente a prática delitiva, o que foi utilizado por esta magistrada em sua fundamentação – inteligência da Súmula nº 545, STJ. Assim, mantenho a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, por se tratar de circunstâncias igualmente preponderantes.

Em terceira fase, no que se refere à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, verifico que o Réu não preenche os requisitos exigidos, em especial, a primariedade e os bons antecedentes (fls. 50/52).

Com relação à causa de aumento contida no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, relativa à proximidade da Igreja Assembleia de Deus Belém (10m), não incide à espécie a referida majorante, uma vez que tal entidade não foi expressamente contemplada pelo legislador no referido dispositivo legal, o que impede a analogia em desfavor do Réu. Neste sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. REGIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. (...) 2. Uma vez que, no Direito Penal incriminador, não se admite a analogia in malam partem e porque a hipótese dos autos (tráfico de drogas cometido em local próximo a igrejas) não foi contemplada pelo legislador no rol das majorantes previstas no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, deve ser afastada a causa especial de aumento de pena em questão.

3. Não há como ser reconhecida a incidência da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas aos acusados possuidores de maus antecedentes. 4. (...). 5. Ordem parcialmente concedida, para afastar a majorante prevista no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas e, por conseguinte, reduzir a reprimenda da paciente para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. (STJ; HC 528.851/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020).

No que se refere à proximidade de unidade básica de saúde (cerca de 130m de distância) registro que o flagrante ocorreu por volta das 17h de um sábado/feriado (1º de maio de 2021), ou seja, em horário e dia sem expediente na referida entidade hospitalar, consoante se verifica em site oficial da Prefeitura de Suzano.

Do mesmo modo, no que concerne à Escola Tochichico Yochicava (cerca de 180m de distância), além de se tratar de dia não letivo, o flagrante ocorreu durante a pandemia causada pela propagação do vírus Sars-Cov-2 (Covid-019), em maio de 2021, não havendo provas nos autos que permitam inferir que, de fato, nesta época do ano, havia aulas na instituição de ensino em questão. Consoante se depreende de notícias jornalísticas veiculadas, as aulas totalmente presenciais retornaram somente no mês de agosto de 2021 e, nos meses anteriores, havia atividades espaçadas, de acordo com a capacidade de distanciamento de cada instituição de ensino, o que não permite a conclusão de que havia, de fato, risco efetivo aos alunos da escola estadual na data do crime.

Assim, à míngua da incidência de circunstâncias modificativas na terceira fase da dosimetria, fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira do Réu que permita valoração diversa.

Fixo o regime fechado como inicial para cumprimento de pena, com fundamento no art. 33, §§ 2º e 3º, CP, tendo em vista se tratar de Réu reincidente, condenado a pena superior a quatro anos de reclusão.

Deixo de substituir a pena por restritivas de direito, em razão do não

preenchimento dos requisitos legais (art. 44, CP), em especial, a não reincidência em crime doloso e o quantum de pena aplicado. No mesmo sentido, o Réu não faz jus à suspensão da pena, com fundamento no art. 77, CP.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para declarar Danilo Fidelis Nunes como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, CONDENANDO-O ao cumprimento de em 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em seu valor unitário mínimo, reajustado desde a prática delitiva.

Em observância ao previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito, por se tratar de crime cuja vítima é a coletividade/saúde pública, não sendo possível valorar, de forma individualizada, o prejuízo causado pela consumação do delito. Indefiro ao Réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, CPP), porquanto respondeu a todo o processo preso, não fazendo sentido deferir a sua soltura neste momento, após decreto condenatório com regime de pena inicial fechado. No mais, trata-se de pena fixada em quantidade superior a quatro anos e de acusado reincidente.

Expeça-se guia de cumprimento provisório de pena à vara de execuções criminais.

Após o trânsito em julgado: a) oficie-se ao instituto de identificação do Estado; b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de cumprimento do previsto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal; c) expeça-se guia de execução definitiva.

Custas na forma da lei (artigo 804, CPP).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Suzano, 22 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA